

1502730-80.2022.8.26.0472

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... do mínimo legal, para os delitos de tráfico e de associação para o tráfico, na medida em que destacou a quantidade e a natureza da droga apreendida - 1 porção de cocaína (84,69g) e outras 5 porções da mesma substância (1,93g) - e o fato de o paciente se valer de familiares de detentos para o transporte de entorpecentes.

(...)

Dessa forma, levando-se em conta as penas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, . - Centro

CEP: 13660-017 - Porto Ferreira - SP

Telefone: (19) 3581-2201 - E-mail: portoferr2@tjsp.jus.br

1502730-80.2022.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502730-80.2022.8.26.0472

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

PATRICK CALIMAN VIEIRA

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de PATRICK CALIMAN VIEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, afirmando que em 31 de março de 2022, por volta de 08h45min, nas imediações da quadra poliesportiva situada na rua Manoel F. Amaral, Jardim Aníbal, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, trazia consigo 76 porções de "cocaína" com peso bruto de 124,0 gramas e 43 porções de "crack" com peso bruto de 9,0 gramas.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "guardas municipais realizavam ronda pelas imediações da quadra poliesportiva municipal situada no local dos fatos, onde ocorre um projeto social da Prefeitura, quando ali avistaram o denunciado em posição típica de traficância, pois postado em pé atrás da quadra com uma sacola plástica nas mãos, comportamento semelhante ao comumente utilizado pelos vendedores de drogas daquela região. Diante da fundada suspeita de cometimento de crime em local público e de interesse municipal, em plena luz do dia (8h45 da manhã) de uma quinta-feira, os agentes se aproximaram para melhor averiguar, ocasião em que o denunciado empreendeu fuga e dispensou ao solo a sacola

que trazia consigo, sendo, contudo, perseguido e capturado. A sacola plástica avistada com o denunciado foi recuperada e apreendida, a qual continha 64 eppendorfs grandes contendo cocaína e 12 eppendorfs menores contendo igual entorpecente, além de 43 porções de crack e a quantia de R\$ 64,00 em notas variadas. Formalmente interrogado pelo Delegado de Polícia após ser advertido de seus direitos, em especial o de permanecer em silêncio, o denunciado optou por confessar os fatos, asseverando que "Com relação aos fatos ora tratados, respondeu que é usuário de crack há muitos anos e atualmente está morando na rua nesta cidade. Que no dia de hoje estava no bairro Jardim Anibal, próximo a quadra poliesportiva, vendendo entorpecentes juntamente com o indivíduo de alcunha "Miojo", o qual não sabe declinar maiores dados, quando guardas municipais chegaram. Que correu dos guardas, mas eles conseguiram o capturar. Que estava carregando uma sacola contendo cocaína e crack, e no bolso de sua bermuda havia a quantia de R\$ 64,00 e um celular. Que o indivíduo de alcunha "Miojo" conseguiu fugir antes da chegada dos guardas e ele é o responsável pelos entorpecentes do local" (fl. 04). Assim, as circunstâncias e local da prisão, com a visualização do denunciado em posição típica de traficância, pois postado em pé com uma sacola plástica nas mãos, além de ter empreendido fuga assim que os agentes públicos se aproximaram, a quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, a apreensão de quantia em dinheiro em notas fracionadas, além de sua confissão, demonstram, com segurança, que ele trazia consigo os entorpecentes com a finalidade de tráfico. Tem-se, ainda, que o denunciado praticou a traficância nas imediações da mencionada quadra poliesportiva."

A denúncia não foi recebida por ausência de justa causa.

O representante Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito às fls. 145/154.

O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial em acórdão de fls. 216/225 determinando o recebimento da denúncia.

Foi apresentada defesa prévia às fls. 331/335, após a citação de fls. 330.

Foi realizada audiência de instrução com apresentação de alegações finais pelas partes.

Quanto ao estado de liberdade, o Tribunal de Justiça determinou, por acórdão de fls. 216/225, a prisão da pessoa imputada.

O mandado foi expedido às fls. 241/242.

Há notícia do cumprimento às fls. 280/283.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico (finalidade da proteção penal) é a saúde pública.

No caso em exame, há prova da existência do crime e de sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11/12), pelos laudos periciais (fls. 271/273) que resultaram positivos para as drogas encontradas e, sobretudo, pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, o guarda municipal Wilson Rogerio Ferreira, na fase policial disse que: "nesta data em patrulhamento pelo bairro Jd. Anibal com o GCM

Oliveira, passaram pela quadra poliesportiva onde ocorre um projeto social da Prefeitura, além exame prático para habilitação de veículos automotores, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, atrás da quadra, levando consigo uma sacola plástica; que tal indivíduo ao perceber a presença policial deixou o local caminhando rapidamente e, em seguida, correu, sendo acompanhado pelo GCM Oliveira que logrou capturá-lo cerca de um quarteirão do local de início; que, tal indivíduo durante

a fuga dispensou a sacola a qual foi recuperada constando que dentro dela havia 64 microtubos grandes de cocaína além de mais 12 microtubos pequenos também com cocaína, 43 pedras de crack e R\$ 64,00 em notas fracionadas e em revista pessoal localizado um aparelho celular; que tal pessoa se identificou como Patrick Caliman Vieira narrando ainda ser morador da cidade de Tambaú, e estava morando nas ruas desta cidade, traficando para sustentar seu vício em drogas; Assevera o depoente ao avistarem Patrick próximo à quadra, haviam vários alunos realizando a prova do Detran; Afirma, ainda, que há diversas denúncias que aportam na base da GCM indicando o local em questão como ponto de venda de drogas." Em juízo manteve sua versão. O acusado estava sozinho. Não conhecia Patrick.

A testemunha de acusação, o guarda municipal Daniel Fernando de Oliveira, na fase policial disse que: "em patrulhamento com o GCM Ferreira pelo bairro Jd. Anibal, avistaram um indivíduo em atitude suspeita próximo a quadra poliesportiva, o qual ao perceber a presença policial se evadiu dispensando uma sacola plástica; que, correu atrás do indivíduo e conseguiu detê-lo ha cerca de um quarteirão, e na sacola que havia dispensado estavam 64 microtubos grandes de cocaína e 12 microtubos pequenos também de cocaína além de 43 pedras de crack e R\$ 64,00 em notas fracionadas e em revista pessoal foi localizado um aparelho celular; que, identificado como Patrick Caliman Vieira este confessou que estava traficando, sendo então levado ao Pronto Socorro para exame cautelar e apresentado nesta Delegacia para providencias de praxe; que, afirma que o local em questão é ponto de venda de drogas e há cerca de um mês abordou outro indivíduo naquele local sendo preso em flagrante por tráfico." Em juízo manteve sua versão.

PATRICK CALIMAN VIEIRA, em declarações perante a autoridade policial disse que: "é usuário de crack há muitos anos e atualmente está morando na rua nesta cidade. Que no dia de hoje estava no bairro Jardim Anibal, próximo a quadra poliesportiva, vendendo entorpecentes juntamente com o indivíduo de alcunha "Miojo", o qual não sabe declinar maiores dados, quando guardas municipais chegaram. Que correu dos guardas, mas eles conseguiram o capturar. Que estava carregando uma sacola contendo cocaína e crack, e no bolso de sua bermuda havia a quantia de R\$64,00 e um celular. Que o indivíduo de alcunha "Miojo" conseguiu fugir antes da chegada dos guardas e ele é o responsável pelos entorpecentes do local." Em juízo disse que atuava como olheiro de Miojo. Estava com as drogas que era de seu uso (tinha duas porções de crack e foi buscar outras duas). Não conseguiu correr porque estava sob efeito de drogas. Policiais abordaram, lhe deram chutes na costela e na coxa. Perguntaram quem era aquele que correu, ameaçando-o; disseram que não eram de correr, era de matar. A sacola encontrada era do tal Miojo. Não correu. Depois de solto, no dia seguinte foi abordado pelos policiais e foi novamente ameaçado por eles. Desceu para pegar duas porções de crack, mas retornaria para se manter na função de olheiro. É de Tambaú e estava havia um mês em Porto Ferreira; moirava na rua. Conseguia dinheiro pedindo para as pessoas e atuando como olheiro. Estava como olheiro havia 14 ou 15 dias.

Embora Patrick tenha dito que as drogas estavam na posse de Miojo, trata-se de circunstância irrelevante para a análise da imputação, pois tais drogas se destinavam à atividade de tráfico para a qual concorria.

Em relação à preliminar levantada pela defesa e, aliás, no mesmo sentido das minhas decisões anteriores no processo, tenho que uma circunstância verificada em audiência é justificadora da alteração do julgamento.

Inegável que os guardas municipais agiram fora de suas atribuições e que não havia certeza visual do delito a justificar a realização de busca pessoal no momento em que tomaram essa decisão. No entanto, diz o acusado que a sacola de drogas foi

jogada pelo seu comparsa o que implica afirmar que a prova não foi colhida mediante busca pessoal.

Neste contexto, ao se depararem com os objetos jogados passaram a ter, então, a certeza visual do crime.

Tal contexto também torna irrelevante o enquadramento da atuação dos guardas nas suas funções constitucionais, pois, diante da visualização do delito a voz de prisão podem dar na condição de qualquer do povo (art. 301 do Código de Processo Penal).

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da base em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.

AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.

AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.

(...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, “reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa” (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...)

Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vitoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., REsp.

1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

Portanto, em referência ao critério da natureza da droga, por constarem da Lista F do Anexo I (substâncias de uso proscrito, ou seja, proibidas sob quaisquer circunstâncias ou concentrações pela natureza intrinsecamente nociva que possuem), merecem valoração nesta fase a maconha e cocaína, sendo que esta em especial (e em maior grau o crack, seu derivado), por causar severa dependência em seus usuários. O STJ, responsável pela uniformização da aplicação do direito infraconstitucional, tem entendido como razoável o aumento de um décimo na pena-base para quantias em torno de 100g de cocaína, como no HC 437972/SP (Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018). Ver também:

No caso, observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento o art. 42 da Lei de Drogas, elevou a pena-base em 1 ano, em razão da aferição desfavorável da quantidade e da natureza da droga (120 g de cocaína).

Tendo sido indicados elementos válidos para a majoração da reprimenda básica, uma vez que significativo o quantum e altamente nociva a substâncias apreendida, não se identifica a alegada contrariedade do art. 59 do CP, sobretudo quando tais circunstâncias foram elencadas legalmente como preponderantes, e as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas são de 5 a 15 anos de reclusão.

STJ, HC 431541/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018.

Os elementos existentes nos autos informam que o Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento ao apelo defensivo para declarar extinta a punibilidade pela prescrição em relação ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, mantendo, no mais, a condenação do recorrente à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa se insurge, inicialmente, contra o quantum de aumento da pena-base argumentando ausência de fundamentação para a sua majoração em dois anos acima do mínimo legal.

Sem razão, porquanto as circunstâncias em que ocorreu o delito e a quantidade e variedade do entorpecente apreendido (08 porções de cocaína petrificada pesando no total 55,030g e 27 porções de maconha, com massa bruta total de 6.303,75g) justificam o aumento da pena basilar. Nessa linha: HC n. 430.461/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 16/04/2018 e HC n. 434.195/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma DJe 01/03/2018.

AgRg no AREsp 1347544/GO, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018.

Da leitura atenta dos excertos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem estabeleceu, em decisão suficientemente motivada, as penas-bases acima do mínimo legal, para os delitos de tráfico e de associação para o tráfico, na medida em que destacou a quantidade e a natureza da droga apreendida - 1 porção de cocaína (84,69g) e outras 5 porções da mesma substância (1,93g) - e o fato de o paciente se valer de familiares de detentos para o transporte de entorpecentes.

(...)

Dessa forma, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos delitos, o deslocamento das pena-base para 7 anos de reclusão e para 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, respectivamente, para os crimes do art. 33 e 35 da Lei de Drogas, é suficiente e adequado à reprovação da conduta delitiva, em razão da quantia e da nocividade dos entorpecentes apreendidos e da conduta social do agente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

STJ, HC 452708/SP, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018.

(...) as instâncias antecedentes consideraram a quantidade e a variedade de droga apreendida - 50 frasquinhos de cocaína (28,9g) e 45 pedras de crack (6g) - para majorar a pena inicial em 1/6, o que não se mostra desproporcional.

STJ, HC 458961/SP, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018.

Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da Vigésima Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo/SP à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Eis os termos do decísum, no que interessa:

6.- Passo a fixar a pena, enquadrando a conduta do réu no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. É necessária a fixação da pena-base do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais manifestamente desfavoráveis, conforme autoriza o artigo 59 do Código Penal. Trata-se de 11 porções de cocaína, acondicionadas em plástico transparente, com o peso líquido de 11,0 g e 158 porções de "crack", acondicionadas em papel alumínio, com o peso líquido de 78,3 g, que seriam destinados a um grande número de pessoas desta cidade. Sendo assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em sete anos de reclusão e setecentos dias-multa.

(...)

Não se vislumbra, in casu, manifesto constrangimento ilegal no tocante à exasperação da pena-base, porquanto foram adotados elementos concretos para justificar a dosimetria, não parecendo arbitrário ou desarrazoado o quantum imposto tendo em vista a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas - 11 porções de cocaína (11 g) e 158 porções de crack (78,3 g) (fl. 14) -, a atrair a incidência do art. 42 da Lei n.º 11.343/06.



(...)

devidamente fundamentada a manutenção do regime inicial fechado, com base nas circunstâncias do caso concreto, não há ilegalidade a ser sanada.

STJ, HC 326418, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015.

Seguindo este raciocínio, a reprimenda pela maconha deve ser feita em patamar inferior (metade) e a valoração negativa pelo crack em patamar superior (dobro). Nem se alegue a existência de julgados no STJ em que são mantidas decisões com aumentos menores de pena a quantidades maiores de drogas. É preciso ler corretamente a jurisprudência da corte e entender que no julgamento de habeas corpus ou de recurso exclusivo da defesa apenas se verifica se houve excesso contra o réu, inexistindo o refazimento da dosimetria pelos ministros segundo os seus parâmetros (até porque, segundo remansosa jurisprudência da corte, isso implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório - "Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena", STJ, HC 462899, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/10/2018, DJe 05/11/2018). Percebe-se, desta forma, que a valoração aqui indicada não é considerada excessiva pelos tribunais superiores.

Nem se alegue também que há aqui tarifação na dosimetria. Apenas se cumpre a determinação da lei especial de graduar a pena segundo a dimensão da ofensa ao bem jurídico; o que é sempre preferível, pois fixa a sanção privilegiando as condições do fato em detrimento das condições do autor.

Assim, conjugando as drogas apreendidas com as quantidades encontradas, aplico um acréscimo de um décimo do intervalo nesta fase.

Segunda etapa. Presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (certidão de objeto e pé de fls. 64/67, autos 1500111-17.2021.8.26.0472). Conforme dispõe o art. 67 do Código Penal, a confissão só tem valor preponderante quando associada à personalidade do réu. No caso, a confissão foi feita sem qualquer demonstração de arrependimento resumindo-se à confirmação do já explicitado no flagrante, de modo que deveria prevalecer a reincidência com um aumento de 1/6 (um sexto). Além disso, nos casos de confissão qualificada, é questionável depreender do relato da pessoa imputada algum arrependimento, visto que ao seu relato vem acoplada uma pretensa justificação. A demonstração desse arrependimento revela a compreensão, por parte da pessoa imputada, do caráter reprovável de sua conduta, revelando um prognóstico melhor de sua reeducação, podendo as finalidades da pena serem alcançadas em tempo menor de cumprimento. O valor preponderante da confissão, assim, deve estar associado a este arrependimento. Todavia, tendo em vista a função constitucional dada ao STJ, principalmente na alínea "c" do inciso III do art. 105, e a consolidação do entendimento pela Terceira Seção, a qual reúne todos os ministros das turmas com competência criminal da corte, faço a compensação das circunstâncias e mantenho a pena no patamar indicado.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

A reincidência exige o regime inicial fechado e impede a aplicação do redutor, bem como a incidência dos institutos despenalizadores.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR PATRICK CALIMAN VIEIRA à pena de reclusão, pelo prazo de seis anos, em regime inicial fechado, bem como a 600 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 33 da Lei

11.343/06.

Diante da declaração do réu a respeito de sua dependência química, determino que o estabelecimento responsável por sua custódia providencie o tratamento de drogadição após avaliação médica competente.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar decretada pelo tribunal estão mantidas.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes.

STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Aliás, a custódia cautelar em casos análogos tem sido mantida pelos tribunais superiores:

3. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado.

4. Na espécie, a custódia cautelar foi mantida para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos agentes - cocaína (13 pinos), crack (53 pedras) e maconha (72 trouxinhas).

5. Ordem denegada.

STJ, Sexta Turma, HC 375559/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016.

O tempo de prisão preventiva não autoriza, por hora, qualquer mudança em seu regime prisional.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF. Todavia, por serem inservíveis e antieconômicos para a SENAD, determino a destruição ou doação dos seguintes bens: 01 telefone celular da marca Samsung.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 4 de outubro de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA